

1500401-20.2021.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... aos delitos de associação para o tráfico - art. 35, lei 11.343/06 e direção perigosa - art. 309, CTB; e, em relação ao delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, "d", do CP e da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado - art. 33, §4º, do CP. Por fim, a defesa da corré Josiane pediu sua absolvição em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500401-20.2021.8.26.0185 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-20.2021.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314791/2021 - DEL.POL.POPULINA, 21473648 - DEL.POL.POPULINA, 162/21/609 - DEL.POL.POPULINA, 2314791 - DEL.POL.POPULINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR RODRIGUES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA (com qualificação às fls. 57), como incurso no art. 33, "caput"; e art. 35, "caput", ambos da lei n. 11.343/06, c.c. arts. 29 e 69 do Código Penal; e art. 309 da lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 69 do Código Penal; e contra JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (com qualificação às fls. 49), como incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da lei n. 11.343/06, c.c. arts. 29 e 69 do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 15:00hs, na Rodovia Antônio Alduino, no município de Populina/SP, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, estando desde antes, até pelo menos a data dos fatos, associados entre si para prática,

reiterada ou não, de crime de tráfico de drogas, adquiriram, guardaram e transportaram, para fins de entrega e fornecimento a terceiros, mais de 10kg (dez quilos) de substância entorpecente e que determinam dependências físicas e psíquicas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que nas circunstâncias acima, em vias públicas da região, o denunciado CAIO conduziu veículo automotor sem ser habilitado, gerando perigo de dano. Autuados em flagrante, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao acusado CAIO, sendo concedida, por outro lado, a liberdade provisória à acusada JOSIANE (fls. 91ss). A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 146ss). Citados (fls. 194; e 237), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 238ss; e 261ss). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. Os réus foram interrogados. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as provas produzidas comprovam a materialidade delitiva e a autoria atribuída aos acusados. Por sua vez, a defesa do corréu Caio pediu sua absolvição quanto aos delitos de associação para o tráfico - art. 35, lei 11.343/06 e direção perigosa - art. 309, CTB; e, em relação ao delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, "d", do CP e da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado - art. 33, §4º, do CP. Por fim, a defesa da corré Josiane pediu sua absolvição em razão da ocorrência de erro de tipo inevitável, pois desconhecia que seu irmão buscava drogas; subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida em juízo é parcialmente PROCEDENTE. Com efeito, finda a instrução probatória, entendemos pela absolvição da acusada JOSIANE (por ambos os delitos), de modo que a autoria e materialidade vieram demonstradas a contento apenas com relação aos delitos previstos no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e em relação ao corréu CAIO. Neste ponto, a materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 03ss); auto de exibição e apreensão (fls. 07ss); laudo de constatação (fls. 80ss); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 143ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual forma, no tocante à autoria, apenas a de CAIO está configurada, restando afastada a de JOSIANE. Vejamos.

O policial militar EBERT ALEXANDRE FABRETE DA CUNHA, em juízo, disse que já atendeu ocorrência do acusado Caio, envolvendo violência doméstica, e que ele é bastante conhecido no meio do tráfico na cidade de Fernandópolis/SP; que na data dos fatos receberam informações de que Caio iria buscar "maconha" no município de Jales/SP; que então se posicionaram próximo ao trevo de Estrela d'Oeste/SP com o intuito de localizá-lo; que viram quando Caio "apontou" com seu veículo VW/Gol, que já era conhecido como sendo de sua propriedade; que antes mesmo de darem a ordem de parada, o acusado já adentrou no trevo de Estrela d'Oeste em alta velocidade e seguiu no sentido de Fátima Paulista/SP; que o distrito de Fátima Paulista/SP é bem pacato, sendo que ele passou em alta velocidade sobre locais de parada obrigatória, lombadas, valetas e etc.; que a via principal da cidade possui bares e praças, sendo que ele passou ali em alta velocidade; que em seguida ele acessou a rodovia que liga à cidade de Populina/SP, continuando a empreender fuga; que no trevo de Populina/SP ele adentrou na contramão da direção, em alta velocidade, mas perdeu o controle do veículo e se chocou contra um coqueiro; que então conseguiram realizar a abordagem; que Caio estava conduzindo o veículo e sua irmã Josiane estava no passageiro; que Josiane também é conhecida nos meios policiais; que ali localizaram um saco preto no assoalho do banco do passageiro, onde estava Josiane; que na porta de Josiane tinha um tablet de "maconha", encaixado no porta-objetos; que Josiane recebeu atendimento médico; que Caio disse que buscou a droga em Jales, tendo utilizado o telefone de Josiane para contactar o traficante; que receberam as drogas às margens da rodovia; que Josiane alegou que foi até Jales para buscar um aparelho celular, sendo surpreendida com os entorpecentes; que Caio declarou que a

droga era dele; que a informação de que Caio buscava drogas obtiveram através de abordagens informais; que nunca teve ocorrência com Josiane; que a conhecia apenas de nome, como sendo "Josiane irmã do Caio"; que o conhecimento era por tráfico; que a apreensão de drogas deste porte destoava do comum no município, pois normalmente apreendem drogas já fracionadas; que esta foi uma das maiores apreensões dos últimos anos; que as informações que receberam diziam respeito apenas à Caio; que, antes de darem sinais, ele já empreendeu fuga; que nas abordagens surgia o nome de "Josiane irmã do Caio".

O policial militar THIAGO RAFAEL GROZZA, em juízo, disse que o acusado Caio já é conhecido dos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas; que inclusive o irmão dele está preso em razão de tráfico; que já tinha efetuado a prisão de Caio anteriormente, em razão da prática de roubo; que já haviam abordado Caio alguns dias antes da prisão; que tinham informações de que ele utilizava uma residência para traficância; que naquela data tinha informações de que ele foi com o veículo VW/Gol até a cidade de Jales para buscar grande quantidade de drogas; que se posicionaram próximo à Estrela d'Oeste/SP; que quando o acusado percebeu a presença da viatura, passou a acelerar o veículo, indo sentido Fátima Paulista/SP; que fizeram o acompanhamento, sendo que ele andou em alta velocidade no distrito de Fátima Paulista/SP, ameaçando pedestres; que no trevo da cidade de Populina o acusado entrou na contramão da direção, perdendo o controle e batendo contra um coqueiro; que solicitaram o "samu" em razão dos ferimentos que eles apresentavam; que no interior do veículo encontraram uma grande quantidade de drogas, nos pés da passageira; que receberam as informações através de abordagens informais; que não tinham informações anteriores de Josiane, mas a droga estava nos pés dela; que a informação sobre a busca dizia respeito apenas a Caio; que no trevo não houve tempo para dar a ordem de parada, pois ao avistar a viatura ele já empreendeu fuga; que no acompanhamento deram ordens de parada, mas ele seguiu em alta velocidade; que Caio mencionou que a droga era dele.

O réu CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA, na fase policial (fls. 16ss), disse que foi levar a droga de Jales para Votuporanga; que sua irmã não sabia que aquela maconha lhe pertencia; que pegou a droga em Jales com um homem desconhecido e iria levar para Votuporanga, para outro homem desconhecido; que manteve contato com esse homem pelo telefone; que ao ver as viaturas policiais empreendeu fuga indo sentido à cidade de Populina, onde pegou a contramão e bateu o carro; que não tem carteira de motorista; que iria ganhar R\$1.000,00 (mil reais) para levar a droga até Votuporanga; que o carro lhe pertencia, embora ainda não tivesse transferido para seu nome; que a maconha estava no banco de trás do veículo; que não sabia quantos quilos de droga tinha; que não iria ficar com nem um pouco da droga para uso próprio; que iria levar sua irmã para Ouroeste, dando carona para ela ir até a casa do namorado dela; que fugiu em alta velocidade; reafirma que sua irmã não sabia que estava levando drogas. Em juízo, disse que na data dos fatos passou na casa de sua genitora no período da manhã, quando Josiane disse que queria ir para Ouroeste/SP; que então chamou ela para ir até Jales/SP buscar um celular; que chegando lá um rapaz lhe passou a droga; que Josiane queria descer do carro, mas não deixou ela descer; que no meio do caminho encontrou as viaturas, sendo que ficou desesperado e começou a correr; que não falou para Josiane que iria para Jales/SP buscar drogas; que iria receber R\$1.000,00 (mil reais) para transportar a droga; que quando viu a polícia tentou fugir; que é usuário de drogas; que Josiane não é usuária; que reside sozinho e Josiane morava com sua mãe; que usou o celular de Josiane para falar com a pessoa que forneceria as drogas; que Josiane iria na casa da namorada dela em Ouroeste/SP; que ela fazia "bicos" de doméstica em Ouroeste/SP; que ela posava na casa da namorada dela; que não falou para Josiane para quem iria ligar; que pegou o celular dela pois o seu tinha acabado a bateria; que a droga estava no seu colo, tendo jogado do lado para começar a correr; que não pediu para ela jogar fora a droga.

A ré JOSIANE RODRIGUES DA SILVA, na fase policial (fls. 18), disse que é irmã do corréu Caio; que na data dos fatos, por volta das 11:00h, seu irmão lhe chamou para ir até Jales buscar um telefone celular que ele tinha comprado; que ele pediu seu telefone emprestado para falar com um homem; ele mandou um contato no seu telefone,

que era um rapaz que ele disse que iria falar; que não viu a conversa e não sabe qual foi o assunto; que entrou no veículo com ele por volta de 13:00h e foram para Jales; que ao chegar numa rodovia desconhecida, Caio parou e saiu uma pessoa desconhecida do mato; que tal pessoa estava toda suja, sendo homem, branco, magro e loiro; que Caio começou a dirigir e este homem assobiou no meio do mato; que Caio parou o carro e o homem veio correndo e jogou uma sacola de plástico preta dentro do carro pela porta de trás; que em seguida Caio acelerou e seguiu o caminho; que viu vários tablets de maconha na sacola, sendo que pediu para Caio lhe deixar em Jales; que Caio disse que não iria lhe deixar; que começou a brigar com ele; que Caio seguiu dirigindo pela estrada de Estrela d'Oeste, sendo que começou a fuga quando ele viu as viaturas policiais; que ele andou em alta velocidade dentro da cidade; que ficou brigando com ele; que Caio pediu para jogar fora uma porção de maconha, o que não fez; que em determinado momento Caio bateu o veículo numa árvore; que ele não lhe informou quanto receberia para levar a droga; que não sabia que ele iria buscar drogas; que tem uma namorada em Ouroeste; que não sabia que seu irmão traficava. Em juízo, disse que naquela data estava em casa, procurando carona para ir até Ouroeste/SP, pois sua namorada mora lá, sendo que também trabalha ali; que Caio disse que lhe levaria até Ouroeste/SP, porém antes passaria em Jales/SP para buscar um celular que ele havia comprado; que chegando lá o acusado estacionou numa rodovia, sendo que um indivíduo abriu a porta de trás e "jogou esse negócio" lá atrás; que quando sentiu o cheiro e viu que era um saco enorme, passou a brigar e discutir com Caio; que pediu para ele lhe deixar ali em Jales/SP, mas ele passou a acelerar; que chegando em Estrela d'Oeste ele começou a correr dos policiais; que ficou pedindo para ele parar; que ele bateu o carro e os policiais chegaram; que a pessoa que entregou a droga era magra, estava sem camiseta e muito sujo; que não é usuária de drogas; que mora em Fernandópolis com seus pais; que Caio residia em outra residência; que trabalhava em Ouroeste todos os dias; que no meio do caminho Caio pediu para jogar as drogas pela janela, razão pela qual puxou as drogas do banco de trás e colocou em seu banco; que não jogou as drogas pela janela; que não jogou porque não era sua a droga e ele tinha que assumir as coisas que estava fazendo; que se jogasse "seria mais cúmplice"; que seu irmão pediu seu celular emprestado, pois o dele tinha acabado a bateria.

Pois bem. Da conjugação de todas estas assertivas, entendemos como comprovado apenas o envolvimento do corréu CAIO no encetamento específico do tráfico de entorpecentes - art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. De fato, a extremada quantidade de entorpecentes encontradas em poder do acusado, além das circunstâncias da apreensão, revela indubitavelmente a destinação do material ao comércio e a consequente configuração do delito previsto no art. 33, "caput" de lei n. 11.343/06. Conforme consta, após fuga e perseguição policial, o autor foi surpreendido, quando em direção do veículo VW/Gol, ora ocupado pelos acusados, com diversos "tablets de maconha", num total de 10,5kg do material. Em detalhamento, os policiais militares já tinham informações de que o acusado Caio iria até a cidade de Jales/SP para buscar entorpecentes, sendo que, em diligências próximas ao trevo desta cidade de Estrela d'Oeste/SP, avistaram o veículo conduzido por ele. Ato contínuo, antes mesmo de receber a ordem de parada, ao avistar a viatura policial o acusado já passou a empreender fuga (transitando em alta velocidade em rodovia e também no perímetro urbano), somente sendo possível a abordagem no trevo da cidade de Populina/SP, quando o acusado se acidentou - ingressou na contramão de direção e se chocou contra uma árvore. Com a abordagem, verificou-se que Caio era o condutor do veículo e foi com localizada grande quantidade de drogas (aproximadamente 10,5kg). Pois bem. Neste ponto, observa-se que as defesas sequer se insurgem quanto à efetiva configuração do delito de tráfico (não negam a "materialidade"), rechaçando, em verdade e maior grau, a autoria imputada à acusada Josiane (pois Caio assumiu a propriedade de todo o entorpecente). Afinal, é intuitivo, ou ao menos razoável supor, que mais de 10kg de "maconha", embaladas em "tijolos" ou "tablets", não são destinadas ao uso pessoal, mas sim ao comércio ilegal. E, ainda que Caio alegue que "apenas" iria transportar o entorpecente (recebendo valores para tanto; não iria revender), é certo que houve demonstrativo das condutas descritas na inicial acusatória (aquisição; guarda; e transporte), o que é

nitidamente suficiente para configuração do art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, que se qualifica como um "tipo misto alternativo". A própria fuga em desatino indica que Caio sabia que problemas ocorreriam em caso de abordagem e busca pessoal.

Nesse passo, em razão da confissão de Caio quanto ao delito de tráfico (corroborada por outros elementos de prova; art. 197, CPP), o ponto realmente controvertido se cinge à configuração (ou não) da autoria imputada à acusada Josiane. E, não obstante os bons argumentos apresentados pelo órgão ministerial, entendemos que não há provas suficientes da participação de Josiane. Com efeito, de início, denota-se que Caio assumiu totalmente a responsabilidade pela ação (assim como a irmã), narrativa essa que se une às informações policiais no sentido de que as denúncias eram, de fato, específicas em relação a ele e sem menção ao envolvimento de Josiane, o que retira o eventual caráter isolado da afirmação dos corréus. Ainda, o policial Rafael mencionou que não possuía informações anteriores sobre o envolvimento de Josiane com o tráfico de drogas, ao passo que as informações trazidas pelo policial Ebert sobre Josiane são deveras imprecisas, e sem apontamento de qualquer fato concreto (afirma-se apenas que ela era "irmã de Caio"; e não que estava vendendo ou ajudando este no empreendimento ilegal). Do mesmo modo, os policiais mencionaram que Caio utilizava sua residência para prática do tráfico, porém, todos os elementos dos autos apontam no sentido de que Josiane residia em outro lugar, ou seja, Josiane morava com os pais, enquanto Caio residia sozinho (o que, apesar de não inibir o concurso, ao menos arrefece a hipótese). Em seguimento, a acusada esclareceu as circunstâncias em que ajustada o ingresso no veículo (carona para cidade de Ouroeste/SP), informando, ainda, que pediu para deixar o veículo após tomar conhecimento dos materiais existentes no interior do veículo, o que lhe fora negado pelo acusado Caio. Por certo, ainda que haja algumas incongruências nas versões apresentadas (por exemplo, Caio nega que tenha ordenado que Josiane se desvencilhasse das drogas, ao contrário do mencionado por ela), entendemos que ainda assim há dúvida razoável sobre o efetivo envolvimento de Josiane com os referidos entorpecentes. Oportunamente, não entendemos por desarrazoado o argumento de Josiane, deduzido em interrogatório/autodefesa, no sentido de não querer se desvencilhar das drogas (eventualmente as atirando pela janela), por não deter responsabilidade pelo tráfico. Afinal, há de se pontuar que, de fato, para um agente "leigo" (sem conhecimento detalhado de condutas descritas em tipo penal), o ato de manusear droga, ainda que para arremesso para fora do carro, pode significar um mínimo de envolvimento com o crime (o que não está por total equivocado, porquanto é mesmo algum auxílio ao criminoso), sendo "crível" o argumento se considerado da perspectiva em que a ré o expôs.

Adiante e em reforço à plausibilidade, ainda que mínima, da tese da corré, entendemos que eram mesmo diminutas as alternativas de Josiane no momento em que notou a presença dos entorpecentes no meio do trajeto, pois ela não deteria invariavelmente o controle final da ação empreendida pelo irmão, mormente considerando a simplicidade de cunho social e cultural por ela ostentada. Vale dizer, pouco provável que ela conseguisse parar o veículo, ou deter palavra de comando em desfavor do irmão. Quanto às demais circunstâncias indicadas para corroborar a tese acusatória, não nos parece desarrazoado o empréstimo de aparelho celular para o próprio irmão; tampouco se apresenta desarrazoada a possibilidade de destinação de ligação a pessoas de conduta criminosa, ainda que a contragosto da proprietária do telefone. Adiante, e data venia, também não se mostra desarrazoada sua crença de que o irmão assumiria a responsabilidade pelos materiais (ao mencionar que se negou a jogar os materiais), ainda mais sendo pessoa de seu convívio. No mais, a acusada é primária, não ostentando nenhum registro policial anterior, mencionando ainda o exercício de atividade laborativa informal. Portanto, embora não se afaste por completo, é claro, a possibilidade de ela ter aderido à conduta do corréu, diante deste quadro de dúvida razoável, e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, entendemos que a absolvição de JOSIANE é, no presente, a medida mais adequada.

Em seguimento, da mesma forma, entendemos que não está configurado o delito previsto no art. 35, "caput", da lei n. 11.343/06 - "associação para o tráfico".

Com efeito, o delito em questão exige para sua configuração demonstração inequívoca de que os envolvidos estavam associados com ânimo definitivo e de maneira estável para a consecução da traficância. E, na presente hipótese, entendemos que nenhum elemento de convicção se direciona no sentido de que os réus agissem de maneira estável e com vínculo permanente. Vale dizer, o simples fato de serem irmãos, por si só, não conduz automaticamente a tal conclusão. Da mesma forma, pese estarem juntos no momento da abordagem, não houve demonstrativo suficiente da prática reiterada de atos, de modo estável e permanente, não sendo suficiente, para tanto, as induções decorrentes de um contexto fático único (de forma distinta das hipóteses em que há investigação prévia e colheita de materiais anteriores ao flagrante). Aliás, como já fundamentado anteriormente, entendemos que não há demonstrativo suficiente da participação de Josiane (inexistência de vínculo subjetivo). Em desfecho, ainda que possível a reversão do julgado pela via recursal, é certo que o cenário mais se aproxima, ao nosso ver claro, de uma ação em concurso de agentes (art. 29, do Código Penal), pois a reunião esporádica é insuficiente para caracterizar o delito em questão. Nesse sentido:

"(...) Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. O Tribunal a quo, tendo reconhecido que a reunião do paciente e os demais corréus teria sido eventual, a admitiu como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto objurgado, de que a associação do paciente com os demais sete corréus teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas..." (HC 208.886/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 01/12/2011).

Assim, não tendo sido demonstrada a existência de ânimo associativo estável e organizado, entendemos que a absolvição é medida mais adequada.

Por fim, a prova oral é inequívoca no sentido de que o acusado CAIO empreendeu direção perigosa, com fuga da abordagem policial em alta velocidade e acidente com o veículo (ingressou na contramão de direção e se chocou contra uma árvore). Da mesma forma, o próprio acusado admitiu que não possuía habilitação válida para conduzir veículo automotor por ocasião dos fatos, exatamente como exige o tipo penal. No mais, é cediço que o crime descrito no art. 309 da lei n. 9.503/97 "(...) textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é necessária a ocorrência de perigo real ou concreto (precedentes do STF e desta Corte)". (RHC 56166/BA. Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. j. 05/05/2015. DJe 15/05/2015). Dessa forma, para caracterizar o crime em tela, imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pela elementar do tipo, o que, na hipótese dos autos, foi suficientemente comprovado. Veja-se que o réu conduziu o veículo sem a devida habilitação, dirigindo de forma anormal para evitar ser abordado pela polícia - velocidade excessiva; transitando por rodovias e inclusive no perímetro urbano de Fátima Paulista/SP, onde há bares, praças e etc.; e ainda chegou a se acidentar com o veículo (ingressou na contramão, e em razão da alta velocidade perdeu o controle do veículo), de modo que houve dano e perigo concreto, pois sua conduta colocou em risco a vida de terceiros, gerando perigo à segurança no trânsito.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

I - art. 33, lei n. 11.343/06 - "tráfico".

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, temos, a merecer valoração negativa, a culpabilidade do acusado e a conduta social desajustada. Com efeito a quantidade elevada de entorpecentes apreendidas em seu poder (10,5kg de "maconha") confere contorno de gravidade diferenciada ao caso e culpabilidade anormal ao tipo penal. A quantidade de entorpecentes apreendida com os acusados evidencia maior

afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a "saúde pública", que é violada com qualquer ação típica que envolve pequenas quantidades. Ou seja, ao revés das pequenas porções, a quantidade de entorpecentes, se colocada em circulação, atingiria elevado número de pessoas. O próprio art. 42 da Lei n. 11.343/06 impõe a ponderação, no momento da fixação das penas, da "natureza e a quantidade da substância ou do produto".

Ainda, quanto a conduta social, observo que o acusado praticou o delito durante o cumprimento de pena - livramento condicional em 04/03/2020 (fls. 75), o que demonstra sua conduta desvirtuada perante a sociedade, descaso com a justiça, além de não ter assimilado o objetivo da reprimenda anteriormente imposta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA. 1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa. 3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que a prática delitativa no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 2. Segundo orientação desta Corte, o fato de o agravante ter cometido novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto demonstra a sua recalcitrância na prática delitativa e evidencia fundamento idôneo à desvalorização da conduta social e consequente exasperação da pena-base. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 371.637/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Por tais razões fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, consoante certidão de fls. 74ss - proc. 792-42.2018; e 1501340-22.2020, o réu é reincidente em crime doloso. Por outro lado, entendemos incidente a atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, "d", do Código Penal, haja vista que o acusado admitiu a autoria do delito em ambas as fases da persecução penal. Assim, considerando serem duas as condenações pretéritas do acusado (um delas, inclusive, por delito praticado com violência ou grave ameaça; "roubo"), considerando que a reincidência é circunstância preponderante - art. 67 do CP, compensa-se parcialmente as circunstâncias, elevando-se a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando, nesta etapa intermediária, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há causa para alteração do quantum da pena. Anoto que inaplicável a redutora art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". A comprovação da satisfação do requisito legal, de certa forma, inverte o ônus da prova, incumbindo ao próprio interessado demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência. E essa prova não foi produzida. O acusado, ao revés, ostenta condenações pretéritas que configuram reincidência, o que, por si só, já lhe afasta o direito ao benefício legal (requisitos da primariedade e dos bons antecedentes).

Ademais, a elevada quantidade de drogas apreendidas (policia! mencionou que uma das maiores apreensões dos últimos tempos) revela que não se pode conferir ao réu, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de um mero iniciante na seara criminal.

Enfim, pelo delito de tráfico de drogas - art. 33, lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva em 07 (sete) ANOS, 09 (nove) MESES e 10 (dez) DIAS de RECLUSÃO e 777 (setecentos e setenta e sete) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

II - art. 309 do CTB.

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, temos, a merecer valoração negativa, as circunstâncias do delito e da conduta social do acusado. De início, como já mencionado supra, o réu praticou o delito durante o cumprimento de pena, no gozo do benefício de livramento condicional, de modo que, pelas razões já apresentadas, deve ter valorada negativa sua conduta social. Por outro lado, como já mencionado, o tipo penal em análise exige a ocorrência de perigo real ou concreto para sua configuração. Entretanto, na hipótese dos autos, a direção anormal empreendida pelo acusado não se limitou à esfera do "perigo", causando dano efetivo à integridade física da acompanhante que estava no veículo - corré Josiane, que sofrera diversos ferimentos em razão do acidente causado pelo acusado. Nesse sentido, os policiais mencionaram que houve necessidade de condução de Josiane ao hospital de Ouroeste/SP para atendimento médico, sendo que o exame de corpo de delito realizado demonstra a ocorrência de diversas lesões pelo corpo - escoriações, equimose, ferimentos corto-contuso no nariz e boca e etc. (fls. 61). Assim, a efetiva lesão à integridade física de terceiros transborda as circunstâncias normais do delito em análise, merecendo, portanto, valoração negativa nesta etapa. Assim, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em 08 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, consoante certidão de fls. 74ss - proc. 792-42.2018; e 1501340-22.2020, o réu é reincidente em crime doloso. Por outro lado, entendemos incidente a atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, "d", do Código Penal, haja vista que o acusado admitiu a prática do delito (admitiu a fuga; acesso na contramão e acidente). Assim, considerando serem duas as condenações pretéritas do acusado (um delas, inclusive, por delito praticado com violência ou grave ameaça; "roubo"), considerando que a reincidência é circunstância preponderante - art. 67 do CP, compensa-se parcialmente as circunstâncias, elevando-se a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando, nesta etapa intermediária, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há razões para alteração do quantum de pena. Enfim, pelo delito do art. 309 do CTB, fixo a pena definitiva em 08 (oito) MESES e 05 (cinco) DIAS DE DETENÇÃO.

As penas devem ser aplicadas cumulativamente em razão do concurso material - art. 69, do CP. Enfim, fixo as penas definitivas em 07 (sete) ANOS, 09 (nove) MESES e 10 (dez) DIAS de RECLUSÃO e 777 (setecentos e setenta e sete) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal (pelo art. 33, lei n. 11.343/06); e 09 (nove) MESES e 10 (dez) DIAS DE DETENÇÃO (pelo art. 309, do CTB).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de reclusão da pena cominada ao delito de tráfico, à condenação superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, "b") e à reincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime FECHADO. Destaco que a lei permite o regime semiaberto apenas ao não reincidente (art. 33, § 2º, "b") em condenações deste patamar, sendo, portanto, imperativo de individualização a imposição do regime mais gravoso quando praticado o delito após condenação definitiva por fato anterior. Noutro vértice, em relação ao delito de trânsito, da mesma forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas e as reincidências, e, notadamente, diante da natureza de detenção da pena cominada, quanto a este deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento

iniciado em regime SEMIABERTO.

Por fim, incabível a concessão do sursis penal (CP, art. 77) ou da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), em razão do quantum de pena estabelecido (quantidade total de pena ora aplicada supera os parâmetros máximos autorizadores), além do que as condenações pretéritas do acusado não demonstram que a aplicação de tais benesses sejam suficientes para reprovabilidade da conduta.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR o réu CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput" da lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) ANOS, 09 (nove) MESES e 10 (dez) DIAS de RECLUSÃO e 777 (setecentos e setenta e sete) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO; e como incurso no art. 309 da lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material com o delito anterior, à pena de 09 (nove) MESES e 10 (dez) DIAS DE DETENÇÃO, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Por outro lado, ABSOLVO o acusado CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA da imputação do art. 35, da lei n. 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, ABSOLVO a acusada JOSIANE RODRIGUES DA SILVA, já qualificada nos autos, de todas as imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu CAIO o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Caio, nesse sentido, apresenta duplo risco: a disseminação de entorpecentes na sociedade, bem como o emprego de conduta perigosa (direção de veículo) com finalidade única de lhe salvar o crime. Assim, inarredável a conclusão no sentido de que o mais adequado não é o aguardo de recurso em liberdade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ).

Já em relação à acusada JOSIANE, por estar em liberdade e não haver causa superveniente para decretação de prisão (art. 312, CPP), e notadamente diante do desfecho ora decretado, DEFIRO a ré o direito aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Em seguimento, com fundamento nos arts. 61ss. da lei 11.343/06 c.c 243, P. único, da Constituição Federal, decreto o perdimento do veículo VW/GOL 1.0, cor preta, ano 2006 - placa DQQ6H03/Fernandópolis/SP, (apreendido às fls. 220ss), já que comprovadamente utilizado no empreendimento do delito. Neste sentido, acorde circunstâncias já pormenorizadas em sentença, o réu utilizou o veículo para o transporte dos entorpecentes, e, portanto, deve perder o bem. Da mesma forma, decreto o perdimento do aparelho celular apreendido e relacionado a Caio (Xiaomi; fls. 07), pois há indicativo suficiente de que foi utilizado na prática do delito, ante o ajuste anterior para busca e entrega de drogas. Anoto que o art. 243, P. único, da CF/88 determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes", sendo irrelevante

qualquer discussão profunda sobre a propriedade (a quem pertencia) ou licitude dos bens apreendidos. Por fim, não comprovada a origem lícita, também decreto a perda em favor da União dos valores apreendidos nos autos. Pontue-se ser ônus da defesa a demonstração da origem lícita do dinheiro, o que não foi feito a contento (Caio não comprovou o exercício de trabalho lícito), devendo perder os valores. Assim, reverta-se ao SENAD a relação dos bens e valores declarados perdidos para os fins de sua destinação, face ao art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/06. Expeça-se o necessário.

No mais, condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observada eventual gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se guia de execução definitiva.

Por último, o não reclamo, após o trânsito em julgado, de eventuais bens apreendidos, no prazo de 90 (noventa) dias, importará na alienação ou destruição do bem, conforme art. 123, CPP.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'Oeste, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA